

1501124-41.2021.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Maria Sílvia Gabrielloni Feichtenberger

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/07/2022

... DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE. VETORES DA CULPABILIDADE E DA CONDUTA SOCIAL VALORADOS NEGATIVAMENTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AÇÕES PENAIS EM CURSO. SÚMULA N. 444 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. NÃO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SANTO ANDRÉ

Foro de Santo André

1ª Vara Criminal

Praça IV Centenário, 03 - Santo André-SP - CEP 09040-906

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501124-41.2021.8.26.0540

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2134837/2021 - 01º D.P. SANTO ANDRÉ, 17980414 - 01º D.P. SANTO ANDRÉ, 1469/21/102 - 01º D.P. SANTO ANDRÉ, 1469/2021 - 01º D.P. SANTO ANDRÉ, 2134837 - 01º D.P. SANTO ANDRÉ

Autor :

Justiça Pública

Réu:

Jessica Mosquera Urrego e Ruth Esmeralda Bojaca Gutierrez

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou Jessica Mosquera Urrego e Ruth Esmeralda Bojaca Gutierrez, qualificados nos autos, como incurso no art. 155, § 4º, II e IV do Código Penal, porque no dia 18 de maio de 2021, por volta das 7h, na Avenida Quinze de Novembro nº 50, nesta cidade, agindo em concurso e com unidade de desígnios, subtraíram, para si, mediante destreza, um aparelho celular Iphone 7, avaliado em R\$ 2.400,00 pertencente a Isabella Lazzarini Pinhão.

Eis a descrição dos fatos contida na denúncia: segundo apurado, a vítima caminhava pela via pública ouvindo música no fone de ouvido, com seu celular no bolso, momento em que JESSICA passou ao seu lado e, sem que a vítima percebesse, subtraiu o aparelho. Após a subtração, JESSICA entregou o celular a RUTH, que fugiu do

local. A vítima viu que o som do fone de ouvido começou a falhar e percebeu que o aparelho havia sido subtraído. Imediatamente, um popular apontou JESSICA como a autora do furto e a vítima a abordou. JESSICA telefonou para RUTH, que retornou ao local e devolveu o aparelho à ofendida. Policiais militares seguiram para o local e as indiciadas foram presas em flagrante.

A denúncia foi recebida 25/10/2021 (fls.170/172), a ré Jessica foi citada (fls.212) e a ré Ruth não foi localizada, razão pela qual foi citada por edital (fls.225), contudo, constituiu advogado apresentou resposta à acusação (fls. 175/176.) sendo indeferida a absolvição sumária (fls.233/235).

Em audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidos a vítima, testemunhas e em seguida, as rés foram interrogadas.

As partes apresentaram alegações finais, oralmente.

É o que basta relatar.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal pública em que se busca a responsabilização criminal do acusado pelo delito descrito na denúncia.

Não há preliminares a apreciar. Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, passo ao exame do mérito.

A materialidade dos crimes constantes da denúncia está provada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls.1), termo de ocorrência (fls.13/16), auto de exibição e apreensão (fls.17), bem como pelas provas orais colhidas no processo.

A autoria das acusadas em relação a tais crimes também está demonstrada pelos documentos acima indicados, pelas provas orais colhidas no processo, além dos demais elementos angariados durante o inquérito policial e o processo penal.

A vítima, em juízo, declarou que tinha saído do ônibus e estava indo pegar o trem, com fones de ouvido e o seu celular estava no bolso. Sentiu alguém pegando seu celular. Olhou para atrás e três rapazes apontaram a ré Jessica. Foi conversar com ela e esta negou. Contudo, os rapazes disseram que foi ela e tinha entregue para uma outra mulher. Falou que iria chamar a polícia. Jessica tentou escapar, mas acabou detida, ocasião em que telefonou para amiga e esta veio e devolveu o celular. Os policiais chegaram e prenderam as acusadas. O celular foi devolvido intacto pela ré Ruth.

A testemunha Willian disse que no dia dos fatos estava na Base 18 do Forte quando avistou um aglomerado de pessoas. Foi ao local e a vítima narrou os fatos. Apontou para Sra Jessica como autora da subtração e Ruth como quem devolveu o celular. Elas estavam detidas. As rés confessaram o crime.

A ré Jéssica, em seu interrogatório, aduziu que furtou o celular da vítima e entregou para Ruth. Tinha a intenção de devolver o aparelho.

A ré Ruth, em seu interrogatório disse estava com o celular, mas devolveu para vítima.

Pois bem, não há dúvida pela prova produzida sob o crivo do contraditório que as rés subtraíram o aparelho celular da vítima.

A vítima narrou com riqueza de detalhes como o seu celular foi subtraído e que sentiu o momento que Jessica retirou de seu bolso.

A testemunha ouvida em juízo confirmou que foi verificar o que estava acontecendo, pois havia um aglomerado de pessoas e lá chegando as rés estavam detidas por populares que confirmaram a versão da vítima.

Por fim, as rés confessaram a prática delitiva.

Logo, a condenação das acusadas é medida que se impõe, uma vez que a totalidade da prova oral colhida em juízo é íntegra e coesa, e aponta no sentido de que as rés efetivamente praticaram o delito de furto.

No que tange a qualificadora da destreza esta não restou evidenciada.

Para caracterização da aludida qualificadora, necessário que o agente utilize de habilidade incomum quando da execução do injusto, tudo com o fim de que a vítima não perceba a subtração.

Sobre o tema, a lição de Cezar Bitencourt:

"Significa especial habilidade capaz de impedir que a vítima perceba a subtração realizada em sua presença. É a subtração que se convencionou chamar de punção. A

destreza pressupõe uma atividade dissimulada, que exige habilidade incomum, aumentando o risco ao de dano ao patrimônio e dificultando sua proteção. (...) Sintetizando, a destreza constitui a habilidade física ou manual empregada pelo agente na subtração, fazendo com que a vítima não perceba seu ato. (...) O agente adentra-se, treina, especializa-se, adquirindo habilidade de tal com as mãos e dedos que a subtração ocorre como num passe de mágica, dissimuladamente." (BITENCOURT, Cezar Roberto. in Tratado de Direito Penal - Parte Especial. Vol. III. São Paulo - Ed. Saraiva, 2008. p. 29-30).

No caso dos autos, conforme declarado pela vítima, ela percebeu de pronto a subtração, razão pela qual a qualificadora não incide como bem argumentado pelo ilustre Representante do Ministério Público.

No que se refere a qualificadora do concurso de agentes, esta restou evidenciada pelas declarações da vítima e confissões das acusadas.

Por fim, restou evidenciada a causa de diminuição de pena do arrependimento posterior prevista no art. 16 do Código Penal.

Tal dispositivo prevê que: nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).

As rés restituíram o aparelho celular a vítima de pronto e aquele estava intacto, logo, cabível a aplicação em seu redutor máximo.

Passo a aplicação da pena da acusada Ruth Esmeralda Bojaca Gutierrez.

Na primeira fase da dosimetria penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal: culpabilidade (culpa inerente ao tipo, sem considerações que possam aumentar significativamente a reprovabilidade da conduta); antecedentes (a acusada é primária); conduta social (nada a considerar); personalidade (não há elementos suficientes a considerar que o acusado possui personalidade nociva ou que se trata de pessoa voltada à prática de crimes); motivos do crime (nada a considerar); circunstâncias do crime (normais); consequências do crime (inerentes à espécie); comportamento da vítima (nada a considerar). Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 2 anos de reclusão e o pagamento de 10 dias multa.

Na segunda fase de aplicação de pena, presente a atenuante da confissão, contudo, a pena foi fixada em seu patamar mínimo, não podendo ficar aquém de tal patamar nesta fase de acordo com o Enunciado da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase de aplicação de pena, presente a causa de diminuição de pena do art. 16 do Código Penal, reduzo a pena em 2/3, passando a 8 meses de reclusão e o pagamento de 3 dias-multa, razão pela qual torno-a definitiva.

Fixo o valor de cada dia-multa no mínimo legal (um trigésimo do salário mínimo).

SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, consistentes em: prestação de serviços à comunidade pelo período da pena privativa de liberdade substituída, em entidade a ser designada em sede de execução criminal.

Em caso de revogação, fixo o regime inicial aberto, tendo em vista a quantidade de pena aplicada e as circunstâncias judiciais favoráveis.

Passo a aplicação da pena da acusada Jessica Mosquera Urrego.

Na primeira fase da dosimetria penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal: culpabilidade (culpa inerente ao tipo, sem considerações que possam aumentar significativamente a reprovabilidade da conduta); antecedentes (a acusada é primária, em que pese possuir vários feitos em andamento quando dos fatos, não possuía condenação penal transitada em julgado e entendo que feito em andamento, não pode ser considerado como maus antecedentes, para aumentar a pena, nesta fase, neste sentido o Enunciado da Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça: é vedada a utilização de inquérito policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. Confira-se:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS.

DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE. VETORES DA CULPABILIDADE E DA CONDUTA SOCIAL

VALORADOS NEGATIVAMENTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AÇÕES PENAIS EM CURSO. SÚMULA N.

444 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N.

11.343/06. NÃO INCIDÊNCIA. PACIENTE RESPONDE A OUTRO PROCESSO PENAL. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME PRISIONAL. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL, RÉU TÉCNICAMENTE PRIMÁRIO E COM BONS ANTECEDENTES. REGIME INTERMEDIÁRIO. CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PLEITO PREJUDICADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. A dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68 c/c o art. 59, ambos do Código Penal - CP, e, no caso do delito de roubo, deve ser observada a gravidade do delito, cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico. 3. Na hipótese, a valoração negativa da culpabilidade não está devidamente fundamentada, porquanto os elementos apresentados integram a estrutura do tipo penal, conforme o entendimento desta Quinta Turma no sentido de que a potencial consciência da ilicitude ou a exigibilidade de conduta diversa são pressupostos da culpabilidade em sentido estrito, não fazendo parte do rol das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, logo, não constitui elemento idôneo a justificar a exacerbação da pena-base (RHC 41.883/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 13/4/2016). 4. Inquéritos policiais, ações penais em andamento e até mesmo condenações ainda não transitadas em julgado, não podem ser considerados como maus antecedentes, má conduta social ou personalidade desajustada, e servir de supedâneo para justificar o afastamento da reprimenda básica do mínimo legalmente previsto em lei, sob pena de malferir o princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade. Nesse diapasão, a Súmula n. 444/STJ. 5. A irresignação quanto a ausência de redução da pena diante da confissão espontânea do réu não foi examinada pelo Tribunal a quo, circunstância que impede o pronunciamento desta Corte a respeito, sob pena de indevida supressão de instância. Ademais, fixada a pena-base no mínimo legalmente previsto, inviável a aplicação da atenuante pela confissão espontânea, prevista no art. 65, inc. I, do Código Penal - CP, por força da Súmula n. 231 do STJ. 6. A existência de outros processos criminais, pendentes de definitividade, embora não sirvam para a negativa valoração da reincidência e dos antecedentes (Súmula n. 444 do STJ), podem afastar a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, quando permitem concluir que o agente é habitual na prática delitiva (HC 378.574/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 10/2/2017). 7. Reconhecidas as circunstâncias judiciais favoráveis e a primariedade técnica do réu, a quem foi imposto reprimenda definitiva de 5 anos de reclusão, e considerando que a quantidade de droga apreendida não é elevada - 3,210g de crack - cabível a imposição do regime inicial semiaberto para cumprimento da sanção corporal, à luz do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal - CP. 8. Mantida a pena final em patamar superior a 4 anos de reclusão, resta prejudicado o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, afinal, o paciente não preencheu o requisito objetivo para alcançar o benefício. 9. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a reprimenda ao patamar de 5 anos de reclusão, além do pagamento de 500 dias-multa, e fixar o regime inicial semiaberto para o seu cumprimento. (STJ - HC: 466739 PE 2018/0222231-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 12/02/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2019).

Desta forma, deixo de considerar como maus antecedentes. No mais, a conduta social(nada a considerar); personalidade (não há elementos suficientes a considerar que o acusado possui personalidade nociva ou que se trata de pessoa voltada à prática de crimes); motivos do crime (nada a considerar); circunstâncias do crime(normais); consequências do crime (inerentes à espécie); comportamento da vítima (nada a considerar). Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 2 anos de reclusão e o pagamento de 10 dias multa.

Na segunda fase de aplicação de pena, presente a atenuante da confissão, contudo, a pena foi fixada em seu patamar mínimo, não podendo ficar aquém de tal patamar nesta

fase de acordo com o Enunciado da Sumula 231 do STJ.
Ressalto que as condenações constantes fls. 278/281, não são capazes de gerar reincidência, em conformidade com o art. 63 do Código Penal.
Na terceira fase de aplicação de pena, presente a causa de diminuição de pena do art. 16 do Código Penal, uma vez que as rés devolveram o aparelho celular a vítima, logo em seguida, aos fatos e aquele estava intacto, assim, reduzo a pena em 2/3, passando a 8 meses de reclusão e o pagamento de 3 dias-multa.
Fixo o valor de cada dia-multa no mínimo legal (um trigésimo do salário mínimo).
SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, consistentes em: prestação de serviços à comunidade pelo período da pena privativa de liberdade substituída, em entidade a ser designada em sede de execução criminal.
Em caso de revogação, fixo o regime inicial aberto, tendo em vista a quantidade de pena aplicada e as circunstâncias judiciais favoráveis.
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para o fim de CONDENAR as rés Jessica Mosquera Urrego e Ruth Esmeralda Bojaca Gutierrez, pela prática do delito previsto no art. 155, § 4º, IV, as penas de 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto e o pagamento de 3 dias multa, no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, para cada dia-multa.
Defiro as rés o direito de recorrer em liberdade, considerando que as acusadas foram condenadas as penas a serem cumpridas em regime aberto e que foram substituídas por restritivas de direito.
Deixo de fixar indenização mínima prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pois ausente pedido nos autos, fato que inviabiliza o contraditório e a ampla defesa, bem como se afasta do princípio da congruência.
Nos termos do art. 201, §2º do CPP, comunique-se as vítimas do teor desta sentença. Condene o réu ao pagamento das custas processuais, mas defiro a justiça gratuita.
Após o trânsito em julgado:
Oficie-se ao Instituto de Identificação civil, comunicando a condenação do réu.
Oficie-se ao TRE para os fins do disposto no art. 15, III, da Constituição Federal.
Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Santo André, 21 de julho de 2022.
P.R.I.C.
Maria Sílvia Gabrielloni Feichtenberger
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA